

1501005-70.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... o requerido já foi condenado por tráfico de drogas quando menor de idade (fl.165) e informação colhida no seu interrogatório. Tudo a indicar que o acusado fazia do tráfico o meio de vida desde longa data. Cumpre destacar que o ato infracional, embora não configure maus antecedentes ou sirva para valoração negativa da personalidade e conduta social do agente, é elemento apto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501005-70.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131040/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 24961111 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2131040 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI APARECIDO AVELAR DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

18/07/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 18 de julho de 2022, às 14h30min, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, o réu Sidnei Aparecido Avelar da Silva, apresentado para a teleconferência pela Centro de Detenção Provisória de Caiuá, nas dependências daquela unidade, seu advogado, Dr. Rafael Pinheiro Gomes, OAB/SP 410.960, e as testemunhas Marcelo Maciel de Camargo e Marcelo de Souza Rocha.

Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao interrogatório do acusado, a oitiva das testemunhas e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. Ao final, pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Sidnei Aparecido Avelar da Silva, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 33, "caput", da lei 11.343/06. Narrou que no dia 13 de maio de 2022, por volta das 07h, no imóvel localizado na Rua dos Lambaris, nº44, na cidade de Tarumã, nesta Comarca, Sidnei trazia consigo 23,460g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, o denunciado guardava em sua casa a droga que destinava ao tráfico; mantinha no local 15 porções de maconha, todas individualizadas e embaladas prontas para entrega ao consumo de terceiros; durante cumprimento de mandado de busca policiais localizaram as porções de maconha no quarto do acusado, R\$ 56,00 em notas diversas, mais R\$ 7,00 e telefone celular, em cujo interior foram encontradas mensagens que demonstram o envolvimento com o tráfico de drogas. Notificado, o réu apresentou defesa (fls.147/154). A denúncia foi recebida em 12/07/2022 (fls.156/157). Nesta data foi feita a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação do réu, sob os argumentos de que: policiais fizeram campana e apuraram movimentação típica de ponto de venda de drogas; os policiais apreenderam as porções de maconha escondidas sob o telhado 15 porções de maconha e apreenderam dinheiro; a condenação é justificável pelo relato dos policiais; no celular do acusado há várias mensagens trocadas com outras pessoas indicando a traficância (fl.65 e seguintes), as quais se referem ao período posterior a maioridade civil; o réu admitiu ter vendido drogas nestas oportunidades; incide a agravante do crime cometido durante o período de pandemia e a atenuante da menoridade relativa; deve ser afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado pelas passagens por atos infracionais; deve ser fixado o regime inicial fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; deve ser decretado o perdimento do dinheiro e ser mantida a prisão. A douta Defesa sustentou a absolvição do réu, sob as alegações de que: o réu sustentou que as drogas eram destinadas ao uso próprio; deve a conduta do réu ser desclassificada; no caso de condenação deve ser fixada a pena no patamar mínimo; o réu é menor de 21 anos na idade dos fatos; não ficou caracterizada a agravante do crime cometido durante período de pandemia, a calamidade atingiu a todos e não gera maior reprovabilidade; deve considerado que não integra organização criminoso e faz jus à redução da pena; deve a pena ser convertida em restritiva de direito e ser concedido o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é procedente. A materialidade do delito de tráfico de drogas ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls.06/08), auto de exibição e apreensão (fl.17), laudo de constatação (fls.14/16), laudo pericial do celular (fls.65/104) e laudo de exame químico de entorpecente (fls.105/107). Extraí-se do laudo pericial que foram periciados fragmentos vegetais, com resultado positivo para Tetrahydrocannabinol - THC, substância de uso proscrito no Brasil. A autoria também é certa e atribuída ao acusado, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Em seu interrogatório Sidnei afirmou que é dependente desde os 14 anos e a droga apreendida é sua, para seu consumo. Relatou que havia pix de pessoas devolvendo dinheiro emprestado a eles. Frisou que pagou R\$ 75 nessas 15 porções de maconha, guardou nesse local por ser fácil para pegar, tem irmãos pequenos e não deixa na vista deles. Mencionou que o dinheiro é proveniente de pensão. Negou ter algo contra a testemunha Marcelo. Narrou que fazia bicos com pintura e como servente.

Sobre a mensagem de fls.67/69 explicou que vendia "chá" no tráfico quando menor, "chá" é maconha. Confirmou que ia levar maconha para "Gordão". Contou que quando falou "subir com um flagrante" se referia a um baseado para fumar. Negou vender "pó", eram amigos que vendiam e segurou para eles, conforme alguém vinha entregava e vendia. Negou ter a intenção de vender essa droga apreendida, usaria tudo. Confirmou que teve a intenção de vender "pó" e foi uns dias antes. Admitiu que já foi condenado por tráfico quando menor de idade. Informou que tinha renda diária de R\$ 50 e trabalhava no máximo por 4 dias seguidos. A testemunha Marcelo afirmou ter recebido informação de que Sidnei guardava drogas na casa e em campana constatou movimentação típica de pessoa que vendia drogas. Relatou que em cumprimento ao mandado de busca na casa do réu, ele negou ter drogas na casa. Mencionou ter encontrado um saco entre o caibro e um telhado de Eternit, contendo 15 porções de maconha, cuja propriedade ele assumiu. Narrou ter encontrado cinquenta e poucos reais. Declarou ter vistoriado o celular do acusado e constatou mensagens relacionadas à traficância. Negou ter ele tenha dito a finalidade da droga e origem do dinheiro. Esclareceu que na campana viu que não era um local de guardar, havia uma grande movimentação de molecada que entrava e saía. Falou que eram pessoas de 18 a 20 anos, entravam e saíam rapidamente, assustados. Frisou que a droga estava no telhado da casa, na parte interna da casa, e o dinheiro numa prateleira do quarto. Negou se lembrar de ter achado petrecho relacionado ao uso. Contou que no dia dos fatos não viu movimentação porque chegaram cedo e já entraram. Tais informações foram confirmadas pelo policial Marcelo Souza. Relatou que o policial subiu num suporte, passou a mão sobre as vigas que sustentam o telhado e achou saquinho com várias porções de maconha. Mencionou que num armário havia mais uma pequena porção, tinha cinquenta reais e mais sete reais em sua posse. Disse que o réu assumiu a propriedade da droga, mas não disse a finalidade. Negou ter participado das diligências anteriores. Frisou que o acusado dormia na garagem de sua residência, nesse local acharam o entorpecente. Pois bem. Ressalto que o tráfico de entorpecentes se configura com a prática de várias condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, como tipo misto alternativo que é, a incidência em qualquer delas justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante do momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal. É dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do ilícito penal. O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a classificação da conduta em porte para uso próprio (ou tráfico de drogas, a contrário sensu) se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Os fatos restaram comprovados pela prova testemunhal. O policial Marcelo narrou em Juízo ter feito uma investigação preliminar e durante campana constatou uma movimentação indicativa de tráfico na casa de Sidnei, vários jovens entravam e saíam rapidamente da casa. Os policiais falaram que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão encontraram um saco entre o caibro e um telhado, contendo 15 porções de maconha. O policial Marcelo Souza achou mais uma porção da droga num armário e apreendeu R\$ 56 em espécie e o celular do réu, onde visualizaram mensagens alusivas à venda de drogas. Embora o autuado tenha dito que aquela droga era para consumo próprio, a versão não convence. Primeiro porque o entorpecente guardado pelo réu estava dividido em 16 porções de maconha, já individualizadas e prontas para a venda. Segundo porque o policial Marcelo atestou ter visto em sua casa movimentação típica de tráfico de drogas, com pessoas entrando e saindo rapidamente. Terceiro porque no celular apreendido com Sidnei há vários diálogos evidenciando a dedicação dele à narcotraficância (fls.65/104). Na conversa com interlocutor identificado como "Vd" Sidnei afirmou:

"Fala pra você, mas você não pode segurar pra mim não? Vou ter que subir lá em cima lá de novo. Levar essa fita aqui, baguio se nós já ta aqui pra baixo, Você não pode segurar pra mim não? Vou ter que ir na caminhada ali rapidão ali. Levar pro gordão ali um chá também mano, que eu pegue lá em cima pra ele na hora que eu subi..... Mas é isso mesmo, baguio vou subir lá pra quebra lá". (sic - fl.67).

Sabe-se que “chá” é uma gíria comumente usada por traficantes para se referir a maconha e o próprio acusado admitiu que já vendeu maconha e nesse dia entregou maconha para indivíduo com a alcunha de “Gordão”. Em outro diálogo o réu falou: “Bagulho to aqui na avenida vendo se eu vendo algum pó aqui, bagulho se é louco, mó neurose” (sic – fl.67). Desta vez o réu estava se referindo à cocaína e na audiência confessou ter vendido esse tipo de droga e que ela pertencia a amigos. No celular também foram armazenadas fotografias do acusado com maconha (fl.70) e diversos recibos de transferência via Pix nos valores de R\$ 10, R\$ 20, R\$ 100,00, cuja origem lícita não foi comprovada pela combativa Defesa. Não apareceu nenhuma testemunha para confirmar que realmente Sidnei emprestou dinheiro a alguém e nem é crível que isso tenha acontecido, levando em conta a renda informada no interrogatório judicial. Quarto porque o réu confessou ter vendido “chá” (maconha) e “pó” (cocaína). Quinto porque com o réu foi localizado dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada pela Defesa. Assim, deve ser decretado o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, do CP c.c art. 63 da Lei n.º 11.343/06. Nesse mesmo sentido, cite-se o seguinte julgado: Inexistindo a prova da origem lícita e havendo presunção de que os bens pretendidos eram produto da prática do tráfico, não há falar em restituição, apresentando-se correta a decretação de perdimento dos bens em favor da União, na forma delimitada pelo art. 60 e § 1º, c/c art. 63 da Lei nº 11.343/06 (TJMG, Apelação Criminal nº 2.0040.08.072861-7/001(1), 4ª Câmara Criminal, Rel. Walter Pinto da Rocha. j. 28.01.2009, unânime, Publ. 11.02.2009, destaquei). Muito embora Sidnei alegue ser usuário de drogas, tal fato não impede a condenação pelo tráfico se as circunstâncias apontam para a prática da venda de entorpecentes. Sabe-se que, não raro, usuários de drogas acabam atraídos para o comércio nefando até como uma forma de subsidiar o vício. Porém, a desclassificação pretendida só é admitida quando se comprove que a posse do entorpecente se destina, exclusivamente, a consumo próprio, situação que não se verifica neste caso concreto. As evidências de que existiram atos ilícitos de posse para mercancia não podem ceder lugar para a posse de drogas para uso próprio. Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28. Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas, eis que não milita em favor do acusado qualquer dirimente: A culpabilidade do réu, entendida aqui como índice de reprovabilidade da conduta, é elevada para a espécie, considerada a natureza do delito. O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Não há informação acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. Os motivos e circunstâncias foram inerentes ao tipo. Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase não é caso de aplicar a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal. Isso porque o fato foi posterior ao dia 22/04/2022, em que o eminente Min. da Saúde declarou o fim da emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19 (Ministério da Saúde declara fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pela Covid-19 – Português (Brasil) (www.gov.br)). Por outro lado, incidem duas atenuantes, relativas à confissão espontânea perante Autoridade Judicial e menoridade relativa, eis que o réu tinha menos de 21 anos quando dos fatos. Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), mas mantenho no patamar mínimo em atenção à súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase não há causas de aumento e nem de diminuição da pena. Não deve ser aplicada a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, levando-se em conta que, apesar de não existir outra condenação anterior aos fatos, o requerido já foi condenado por tráfico de drogas quando menor de idade (fl.165) e informação colhida no seu interrogatório. Tudo a indicar que o acusado fazia do tráfico o meio de vida desde longa data. Cumpre destacar que o ato infracional, embora não configure maus antecedentes ou sirva para valoração negativa da personalidade e conduta social do agente, é elemento apto a demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, afastando-se, desse modo, a incidência

da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante o não preenchimento de todos os seus requisitos. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do C. STJ: "O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes" (Habeas Corpus nº 435.685/SP (2018/0024647-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 11.04.2018, destaquei). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no Resp 1560667/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017, destaquei). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) II - No tocante à consideração de atos infracionais anteriores na dosimetria da pena, esta Corte é uníssona no sentido de que não podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes para elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência. Entretanto, este Tribunal tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas, sendo inclusive, fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas. (...) (Habeas Corpus nº 546.923/SP (2019/0349065-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Leopoldo de Arruda Raposo. j. 10.12.2019, DJe 17.12.2019, destaquei). "(...) a existência de atos infracionais cometidos anteriormente pelo paciente, que servem para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de crimes" (STJ, Habeas Corpus nº 538.171/SP (2019/0302012-3), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 03.12.2019, DJe 11.12.2019). HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA PELO MESMO DELITO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. CAUSA DE AUMENTO. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 3. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 01.02.2017). 3 4. O histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de drogas, justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por evidenciar

a sua dedicação a atividades criminosas. (...) (Habeas Corpus nº 510.588/DF (2019/0139105-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 21.11.2019, DJe 05.12.2019, destaquei). Tal entendimento está consolidado de forma pacífica na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, poderia citar dezenas de julgados nesse mesmo sentido. O entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não destoia deste entendimento: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Condenação bem lançada – Pleito defensivo que se restringe à pena e ao regime prisional estipulados – Aplicação do redutor aludido no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 – Desacolhimento – Circunstâncias da apreensão que revela aprofundado envolvimento do réu com atividades criminosas – Atos infracionais que, malgrado não se prestem para recrudescer a básica, podem ser invocados para obstar a aludida minorante – Precedente do STJ – Regime fechado adequado à gravidade concreta dos fatos – Tráfico de maconha e cocaína, estupefaciente este altamente nocivo – Quantidade de drogas com aptidão para atingir diversas dezenas de usuários Substituição da pena defesa (art. 44, I, do CP) – Sentença irreparável – Recurso desprovido. (TJSP, apelação nº 1513738-30.2019.8.26.0320, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.29/09/2020, destaquei). Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Preliminar inconsistente. Alegada majoração da pena por prática de atos infracionais. Inocorrência. Circunstância, ademais, sanável por esta via, se ocorrente. Ausência de prejuízo. Fundo. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policial Militar. Versão exculpatória inverossímil. Necessidade condenatória imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Exasperação da base adequada. Redução por atenuantes aplicada. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º. Acusado que admite a traficância há mais de 2 anos, desde adolescência. Apreensão de narcóticos variados que demonstram envolvimento na criminalidade, ademais. Habitualidade evidenciada. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar. (Apelação Criminal nº 1500194-29.2019.8.26.0302, 4ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Luis Soares de Mello. j. 12.11.2019, Publ. 14.11.2019, destaquei). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA REFERIDA LEI, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO, A DETRAÇÃO PENAL E A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – (...) NA TERCEIRA FASE, AFASTAMENTO JUSTIFICADO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA REFERIDA LEI. A CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENHIDOS, A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LÍCITAS, O RELATO DOS POLICIAIS E O REGISTRO DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS, DENOTAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO, ASSIM, A CONCESSÃO DO REFERIDO REDUTOR. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação nº 0001324-28.2016.8.26.0628, 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Ely Amioka. j. 06.12.2018, Publ. 07.12.2018, destaquei). Assim, muito embora os atos infracionais não sirvam como maus antecedentes, o fato é que Sidnei não é um novato no tráfico de drogas. Tudo indica que já se dedica a isso há muito tempo e faz da traficância seu modo de vida. Seria absolutamente desproporcional dar a ele o mesmo tratamento de uma pessoa que está traficando pela primeira vez. Assim, atinge a pena o montante final de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda apurada no interrogatório e do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, valor que deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi dos antecedentes infracionais do réu, já condenado por tráfico de drogas, da variedade da droga e intensidade da prática demonstradas pelas mensagens de seu celular e recibos de transferência via Pix, do

artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e da regra constitucional prevista no art. 5º, inc. XLIII da Constituição Federal, e de uma política criminal mais rigorosa de repressão aos crimes de tráfico. Justifico a fixação do regime prisional mais gravoso, a não substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena também pelo fato de estarem ausentes os requisitos dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI, da Carta Magna. Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no art. 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. Orig. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.09). O crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Nesse aspecto, acerca da necessidade do regime mais grave para o tráfico de drogas, cito o voto do eminente Desembargador Machado de Andrade, no julgamento da Apelação nº 0004588-12.2016.8.26.0189, julgado em 21/09/2017: “Esse desgraçado vício da cocaína chegou em nosso país e, principalmente, nessa cidade de São Paulo, onde todo mundo sabe que existem logradouros públicos, que foram praticamente tomados por viciados. É bom lembrar que o usuário de cocaína quando não tem dinheiro para adquirir a cocaína pura, que é em forma de pó, passa a se utilizar de uma forma inventada nos Estados Unidos, mais, precisamente na cidade de Nova York, no início dos anos 1970, denominada crack, aliás muito mais potente no sentido de fazer com que apenas com uma aspiração da fumaça tóxica (coloca-se a pedra em um pequeno cachimbo, conhecido como “marica”, geralmente de vidro, esquentada com uma chama de isqueiro ou fósforo, e a pessoa suga a fumaça que desprende da pedra de “crack”) já se torna dependente desta desgraça que foi inventada por indivíduos alheios a qualquer sentimento de piedade e que tinham somente interesse em ganhar dinheiro. Ora, uma pessoa que transforma seu semelhante num morto vivo, ou seja, um verdadeiro zumbi, como os que se vê na mídia, principalmente televisiva, indivíduos convivendo juntos na maior sujeira e promiscuidade, sendo que os locais onde essas pobres almas habitam, tem que ser constantemente lavado, com jatos de água e detergentes, pela Prefeitura Municipal, a fim de remover o fedor que exala do chão devido às secreções e excrementos que essas pessoas deixam naqueles locais. Tudo o que disse acima, e que é do conhecimento de todos, acontece por apenas uma razão, devido à ação de pessoas destituídas de qualquer sentimento de amor ao próximo, como é o caso do traficante e, nesses autos, do acusado. Com relação à conduta social do recorrente, não há qualquer dúvida que, com sua atividade de traficantes, ele causou um mal irreparável à sociedade, uma vez que muitos adolescentes, provavelmente, foram por ele jogados no inferno de uma vida de usuário de drogas. O direito, como é cediço, é uma ciência mutável, ou seja, ele tem que acompanhar a evolução humana, e se adaptar às suas necessidades que mudam a cada época do desenvolvimento da sociedade. Assim sendo, como uma das finalidades da pena é intimidar um possível criminoso, é mais do que óbvio que um crime como o tráfico de drogas, que, sem falar nos males causados à pessoa humana, abre as portas para inúmeros outros delitos, como furtos, roubos, homicídios, prostituição etc.; não pode receber um tratamento menos gravoso do que um delito de menor potencial ofensivo. Assim, ante o terrível mal que o réu causava à sociedade antes de ser preso não há outro regime, senão o inicial fechado, como forma de contraprestação do Estado à sua conduta. Fixar-se um regime mais benéfico do que o inicial fechado, seria conceder-se uma benesse ao réu, a qual ele não é merecedor”. No mais, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade,

não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta cidade. Por fim, foi publicada a Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual “computam-se, na pena privativa

de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. Pelo art. 1º: “a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei”. Já o art. 2º acrescenta o § 2º ao art. 387 do CPP: “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração. Neste caso concreto o réu não cumpriu 2/5 da pena, de modo que não faz jus à progressão. Assim, apesar da detração ora realizada, o regime inicial de cumprimento da pena restante ainda será o fechado. Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR o réu Sidnei Aparecido Avelar da Silva, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita porque se trata de réu pobre; c) DECLARAR a perda, em favor da União, do numerário apreendido nestes autos, com base nos arts. 91, inc. II, do Código Penal, e 63, da Lei nº 11.343/06. Uma vez que se cuida de réu que viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar, ostenta antecedentes infracionais e mostrou reiterada dedicação ao tráfico, a indicar periculosidade, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e as jurisprudências que adoto como razão de decidir, in verbis: “Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHCnº111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013). “(...) Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...)” (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei). Recomende-se o réu no local onde está detido, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional. Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas. Sentença registrada eletronicamente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Decorrido o trânsito em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Expeça-

se ofício ao Banco do Brasil solicitando que efetue a transferência do valor em favor do FUNAD, constando como CNPJ do favorecido o nº 02.645.310/0001-99, banco 001, agência 1607-1, c/c 170500-8, código identificador nº 2002460000120201, e o envio de comprovante nos autos, no prazo de 10 dias; 5) Expeça-se ofício à SENAD, encaminhando cópia do auto de apreensão de bens, sentença de perdimento, certidão do trânsito em julgado e comprovante do depósito, para ciência. Envie-se-o pelo e-mail cdc.funad@mj.gov.br; 6) Expeça-se ofício à Autoridade Policial requisitando a destruição do celular; 7) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 8) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que: a) providenciem, por si ou por procurador, a retirada do celular e veículo apreendidos, no prazo de 90 dias, o celular na Delegacia de Polícia, sob pena de perdimento dos bens; b) pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribua ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva". Em seguida, o(a)(s) Defensor(a)(es) e o(s)réu(s) manifestou(aram) o desejo de recorrer contra a sentença proferida nesta data. Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. 1. Recebo o recurso interposto pelo(a) defensor(a). Sai o(a) Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões no prazo de 8 (oito) dias. 2. Se não forem apresentadas razões no prazo, intime o Advogado para apresentar as razões em 24 (vinte e quatro) horas. 3. Se não fizer, comunique o fato à OAB, nomeie outro Defensor e o intime para apresentar as razões recursais no prazo legal. 4. Expeça-se a certidão de honorários parciais à douta Defesa em 70% do respectivo item do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB. 5. Após a expedição da certidão, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias; 6. Expeça-se a guia de execução provisória e envie-se à VEC competente. 7. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo(s) sentenciado(s), observando-se as formalidades legais. Considerando a pena imposta, anoto que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 17 de julho de 2028 (art. 115 do Código Penal). Saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Eu, Júlia Chacon Saade, escrevente ad hoc, digitei.